

1500255-44.2019.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... demonstrar que o acusado 'se dedique' ao tráfico de drogas. Diante deste contexto, nota-se que não existem indícios suficientes de que a acusada integre organização criminosa ou se dedique de maneira 'profissional', permanente e reiterada ao tráfico - situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, mas, certamente, implica em diferenças, em relação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura - SP - cep 18870-000

1500255-44.2019.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500255-44.2019.8.26.0574

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO AUGUSTO GARCIA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor de WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA, CAIO AUGUSTO GARCIA, MICHAEL WILLYAM CAMARGO VIEIRA e FRANCIELE FREITAS GODOI, todos já qualificados, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 00h30min, na Rodovia SP 249, 178 - Rural, na cidade de Taguaí-SP, WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 08, CAIO AUGUSTO GARCIA, qualificado a fls. 09, MICHAEL WILLYAM CAMARGO VIEIRA, qualificado a fls. 10, FRANCIELE FREITAS GODOI, qualificada a fls. 11, e DANIELA APARECIDA PEREIRA, qualificada a fls. 7, traziam consigo, 17 (dezessete) porções pequenas de cocaína e 01 (uma) porção grande acondicionadas em sacos plásticos, contendo ao todo 49.2 gramas de cocaína, para fins de venda e comercialização, conforme auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 21/22 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda do incluso inquérito policial que, em período incerto mas antes de 13 de outubro de 2019, WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 08, CAIO

AUGUSTO GARCIA, qualificado a fls. 09, MICHAEL WILLYAM CAMARGO VIEIRA, qualificado a fls. 10, FRANCIELE FREITAS GODOI, qualificada a fls. 11, e DANIELA APARECIDA PEREIRA, qualificada a fls. 7, associaram-se para o fim de praticar, o crime de tráfico de drogas inclusive o narrado acima. Os denunciados WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA, CAIO AUGUSTO GARCIA, MICHAEL WILLYAM CAMARGO VIEIRA, FRANCIELE FREITAS GODOY E DANIELA APARECIDA PEREIRA, deliberaram cometer crimes de tráfico de drogas. Foi apurado então que na data dos fatos, DANIELA, MICHAEL, FRANCIELE, estavam na casa de WESLEY e combinaram de todos irem na Festa de Taguai/SP juntamente com CAIO, taxista, para juntos dedicarem-se ao comércio ilícito de entorpecentes. WELSEY, pediu então para que FRANCIELE colocasse o entorpecente dentro de sua roupa íntima, ela acatou o pedido e o fez. Logo após, CAIO, o taxista, chegou para levarem todos os envolvidos para a referida festa. Durante o percurso os denunciados foram abordados pela Polícia Militar. Durante a abordagem FRANCIELE confessou que portava entorpecentes em sua roupa íntima, e retirando os entorpecentes entregou-o a ao milicianos, afirmando que teria os escondido a pedido de WESLEY. Ainda, foi encontrado com CAIO a quantia de R\$787,00 (setecentos e oitenta e sete reais) em notas diversas, com FRANCIELE foi encontrado a quantia de R\$20,00 (vinte reais) e com DANIELA a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Pelas circunstâncias da abordagem, pela forma em que os entorpecentes estavam acondicionados, pelo concurso de diversos agentes, restou evidenciado que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio ilícito" (fls. 153-154).

As prisões em flagrante dos acusados Caio, Wesley e Michael foram convertidas em preventivas. A prisão em flagrante de Franciele foi convertida em prisão domiciliar (fls. 107-111).

Foi decretada liberdade provisória do acusado Caio, por meio de decisão do STJ (fls. 399-405).

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 255-263; 391-393; 394-397; 443-444). Em 08 de abril de 2020, foi recebida a denúncia contra os acusados Wesley Ribeiro Alves da Silva, Caio Augusto Garcia, Michael Willyam Camargo Vieira e Franciele Freitas Godoi; sendo rejeitada a denúncia contra Daniela Aparecida Pereira, com base no disposto no artigo 395, III, do CPP; e, ainda, decretada a liberdade provisória dos acusados, Wesley Ribeiro Alves da Silva, Michael Willyam Camargo Vieira e Franciele Freitas Godoi, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 455-458).

Foi designada data para realização de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 626-629).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas, bem como a inquirição dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 717-731 e mídias anexas).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela parcial procedência. Argumentou que a imputação é improcedente em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, porque não demonstrada a estabilidade da atuação conjunta, ressaltando seu entendimento a respeito da tipificação não exigir o elemento.

Sustentou que devida também a absolvição dos acusados Caio e Michael em relação a imputação do tráfico de drogas, em razão da existência de dúvida de suas participações. Alegou que devida a condenação dos acusados Franciele e Wesley pelo delito de tráfico de drogas, pois os elementos dos autos comprovam suas ações ilícitas. A respeito da dosimetria da pena, argumentou que devida a valoração da quantidade e natureza de drogas, além do reconhecimento de maus antecedentes e reincidência em relação ao acusado Wesley, a quem deve ser atribuído regime fechado, sem a possibilidade de aplicação dos art. 44 e art. 77, do CP. Postulou, ainda, pelo perdimento dos bens apreendidos.

A defesa do acusado Caio apresentou alegações finais (fls. 732-746) alegando, em síntese, que não está comprovada a participação do acusado nos delitos que lhe são imputados. Subsidiariamente, postulou pela fixação de pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP (participação de menor

importância) e a possibilidade de recorrer em liberdade.

A defesa da acusada Franciele ofertou alegações finais (fls. 751-758) argumentando, em síntese, que devida a desclassificação da conduta da acusada ao art. 28, da Lei 11.343/06, sustentando a comprovação de sua condição de usuária. Subsidiariamente, postulou pela imposição de pena no mínimo legal e a possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade.

A defesa de Michael apresentou alegações finais (fls. 760-761) sustentando, em síntese, que não comprovada sua participação nos fatos que lhe são imputados.

A defesa de Wesley apresentou alegações finais (fls. 762-764) sustentando, em síntese, que não comprovada sua participação nos fatos que lhe são imputados, pois a associação para o tráfico não restou caracterizada e, em relação ao tráfico de drogas, a prova em seu desfavor é demasiadamente frágil.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Destaque-se que a defesa de Daniela apresentou tese de ausência de justa causa, a qual foi anteriormente acolhida (fls. 455-458), não havendo, ao momento, outras matérias sujeitas à apreciação.

Por esta razão, possível o julgamento do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. *Justificação e Crítica - perspectivas de uma teoria crítica da política*. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. *Sobre a Violência*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência de fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. *Ônus da prova no processo penal*. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt). https://www.google.com.br/search?q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ

Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas

Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

"DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. A falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente." (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)

"Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida." (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP". (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaquei).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17-18), Auto de Constatação Preliminar (fls. 20-21), fotos (fls. 19-20), Auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), Relatório Final das Investigações (fls. 178-180), laudo pericial da droga (fls. 191-194), laudo pericial dos celulares (fls. 507-529), além da prova oral produzida em juízo.

4. Passo à análise da autoria.

Nesse contexto, as testemunhas Ricardo e Juliano (policiais militares) depuseram em

harmonia e consonância dos fatos, tendo ratificado os depoimentos prestados durante a fase policial.

Especificamente, a testemunha Ricardo (policial militar) narrou, em síntese, que estava de serviço, juntamente com Juliano, e, na parte da tarde, abordaram uma pessoa conhecida por envolvimento com drogas, não encontrando nada de ilícito com o abordado. No entanto, esta pessoa informou sobre um delito de tráfico, que ocorreria na parte da noite, durante a festa do peão, tendo detalhado que os acusados iriam de taxi, com acusado Caio, de Fartura para Taguaí, durante a festa do peão, para a venda de drogas. No momento, o informante passou os nomes de quem seriam os responsáveis pelo tráfico, imputando a prática às pessoas de Wesley, Michael, Caio e 'mais uma moça', que não soube nomear. Afirmou que, então, no período da noite, visualizaram o carro informado e o abordaram, sendo que dentro do veículo estavam os acusados. Em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito com os acusados. Entretanto, notaram o nervosismo da acusada Franciele, quem, então, confessou que estava com as drogas, tendo entregue os entorpecentes voluntariamente. Diante dos acontecimentos, conduziram todos à Delegacia, sendo que, no local, havia policial feminina, que realizou revista pessoal nas acusadas e não tendo encontrado os outros objetos ilícitos. Afirmou que, no momento da abordagem, os acusados disseram que estavam na casa de um deles, em Fartura, e, então, decidiram pela prática da traficância. Relatou, também, que encontraram dinheiro com os acusados, sendo que a maior quantidade estava com Caio, por volta de R\$ 700,00 (setecentos reais). Narrou que, inicialmente, durante a abordagem, Franciele apresentou diversas versões, sendo que, inicialmente, implicava todos os acusados na prática de traficância, mas, quando os acusados ficaram mais próximos, as versões foram alteradas. Relataram que nenhum dos acusados apresentou resistência a prisão. Esclareceu que Franciele teria dito que foi Wesley quem lhe pediu para levar as drogas, sendo que no momento que em fez esta afirmação Franciele não estava próxima de Wesley.

A testemunha Juliano (policial militar) disse que no período da tarde, abordaram um indivíduo conhecido pelo uso de drogas, que teria dito que o acusado Caio, dirigindo um taxi, Voyage branco, se destinaria a Taguaí, juntamente com os demais acusados (tendo nomeado Wesley, Michael e 'mais uma moça'), para vender drogas. Afirmou que, então, passaram o dia procurando pelo carro indicado pelo informante, sendo que no período da noite localizaram o veículo e lhe ordenaram a parada. Disse que, durante a abordagem, inicialmente nada de ilícito foi encontrado, mas a situação provocou estranheza, pois as características batiam com as informações transmitidas a tarde e cada um dos ocupantes do veículo apresentou uma versão sobre a situação. Disse que Franciele apresentou muito nervosismo na conversa e, em seguida, confessou que estava com cocaína em sua roupa íntima, tendo entregue as drogas aos policiais. Segundo a versão apresentada por Franciele, no momento, os acusados (a exceção de Caio) estavam na casa de Wesley, durante a tarde, sendo que Wesley e Michael lhe convidaram para levar as drogas a Taguaí. Afirmou que com os acusados foi encontrado dinheiro, sendo que com Franciele estava a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) e com Caio valores superiores a R\$ 700,00 (setecentos reais). Esclareceu que, na parte da tarde, o informante passou os nomes das pessoas, nomeando "Caio, Wesley e Michael e 'uma moça'". Relatou que Franciele apresentou versões conflitantes, sendo que inicialmente negou a traficância, porém, posteriormente, quando separados os acusados, Franciele confirmou a prática do delito, dizendo que Michael e Wesley lhe convidaram para a prática do delito. Disse que nenhum dos acusados apresentou resistência a prisão. Esclareceu que Franciele apresentou versões contraditórias sobre Caio saber ou não a respeito da droga - sendo que tais informações foram informais, no local dos fatos.

A testemunha Décio apresentou um relato que é basicamente abonatório a respeito de Caio, dizendo que ao tempo trabalhava juntamente com o acusado em um ponto de taxi, porém nunca soube de envolvimento dele com tráfico de drogas.

O acusado Wesley afirmou que estava fazendo um 'esquentão' para ir pra festa do peão, em Taguaí, sendo que, durante a noite, chegaram os demais acusados, exceto Caio. Disse que fizeram uma 'vaquinha' para o transporte e ficaram no aguardo de Franciele, que foi a sua casa tomar banho e, posteriormente, retornou. Relatou que

durante a corrida foram abordados e que não tinha ciência das drogas. Alegou que os policiais e Franciele disseram que a droga era sua, porém isso não é verdade. Afirmou que ao tempo estava de 'saidinha' e errou ao desrespeita-la, porém a droga não é sua e que nem, ao menos, tinha ciência dos entorpecentes. Relatou que no dia seguinte realizaram uma busca e apreensão em sua residência, mas nada de ilícito foi encontrado. Afirmou que não tinha dinheiro consigo e não sabia quem iria pagar a corrida, mas recorda de ter sido Franciele quem chamou o taxi. Disse que Caio iria lhes deixar na festa e retornar para Fatura. Disse que festa é gratuita. Afirmou não ter inimizade com Franciele.

O acusado Caio negou a prática delitativa. Disse que estava por volta das 23h00 - quando já estava em casa, após o dia de trabalho - recebeu uma ligação, de Franciele, solicitando uma corrida de taxi, no endereço da casa de Wesley. Disse que pediram uma corrida a Taguaí, sendo que, no carro, Michael sentou-se no banco da frente, as acusadas e Wesley atrás. Afirmou que no trajeto foram abordados pela polícia militar, sob a alegação de que existiram drogas no veículo. Negou que soubesse dos entorpecentes. Narrou que iria cobrar R\$ 40,00 (quarenta reais) pela corrida e voltaria diretamente pra casa. Afirmou que conhece 'de vista' os demais acusados, não tendo amizade ou inimizade com eles. Disse que o dinheiro encontrado é correspondente aos seus ganhos da semana e é comum manter os valores no carro por algum tempo, pois precisa de troco. Relatou não saber quem pagaria a corrida, mas que foi Franciele que pediu o taxi. Disse que ao longo da semana levou outras pessoas à Taguaí e não sabe se as demais pessoas tinham portavam drogas.

A acusada Franciele afirmou que inicialmente estava em 'chá de bebê' e posteriormente foi à casa de Wesley, em busca de drogas, pois, ao tempo, era usuária de entorpecentes. Disse que na casa de Wesley começou a beber e, então, decidiram ir a Taguaí. Por este motivo, retornou a sua residência, para tomar banho e ligou ao taxi, solicitando uma corrida. Afirmou que, após ter utilizado droga, Wesley lhe deu a droga para levar para Taguai, sendo que não contou para Caio que estavam levando drogas. Relatou não recordar sobre quem iria pagar a corrida, mas disse que, por suas recordações, somente ela teria dinheiro.

O acusado Michael disse que é vizinho de Wesley e, ao ver que ele estava com duas meninas, decidiu ir para a sua casa. Em seguida, lhe convidaram para ir a festa do peão, em Taguí, de taxi. Disse que as demais pessoas estavam na parte de dentro da casa e ele na parte de fora e, com chegada do taxi, todo entraram no veículo, sendo ele quem estava no banco da frente, e rumaram a Taguaí. Disse que não viu a droga, em momento algum. Relatou que era vizinho de Wesley, conhecia Franciele apenas de vista e não conhecia Caio.

5. Diante deste cenário, entendo que ficaram comprovadas autorias e materialidades do delito de tráfico.

No ponto, resalto, em primeiro lugar, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma,

julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

5.1. Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram, em parte, a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

É que, diante do cenário probatório, é possível concluir, para além de dúvida razoável, que a acusada Franciele foi surpreendida em posse de cocaína e dinheiro, após o acusado Wesley ter que entregue a droga para transporte.

Neste contexto, observe-se que os policiais apresentaram versões claras, harmoniosas e verossímeis dos fatos, apontando, sempre, à acusada como sendo a pessoa que carregava a droga e acrescentando que a acusada teria também implicado o réu Wesley na prática delitiva. No mesmo sentido, foi o depoimento da acusada Franciele, em juízo, que afirmou que realmente estava em posse do entorpecente apreendido, após o acusado Wesley, momentos antes – em uma festa em sua casa – ter lhe ofertado para que transportasse a droga à festa do peão, em Taguaí, local em que comercializariam a substância.

No ponto, destaque-se que a acusada apresentou uma tese pertinente a sua culpabilidade para, em tese, justificar seu comportamento, sendo, no entanto, inequívoco que estava com a droga, após esta ter lhe sido confiada por Wesley. Dessa maneira, entendo que estão comprovadas as autorias de Franciele e Wesley, em relação ao tráfico de drogas descrito na exordial.

5.2. Em contrapartida, em relação aos acusados Caio e Michael, conforme já manifestado pelo representante do Parquet (titular da ação penal, nos termos do art. 129, I, da CF), há, ao menos, dúvida razoável a respeito de suas participações.

Note-se que inexistem elementos suficientes para afirmar que os acusados Caio (motorista do taxi) e Michael tinham consciência de que a acusada Franciele transportava drogas a pedido de Wesley, de forma que não estão caracterizadas, de maneira segura, suas participações no delito.

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (grifo nosso).

In casu, a conduta dos agentes se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consumando-se o delito com a prática de qualquer uma das hipóteses previstas, na medida em que as condutas se enquadram na forma descritiva dos tipos penais de: "trazer consigo", "guardar" e "transportar".

Por esta razão, comprovada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

6.1.1. Em relação a acusada Franciele, entendo possível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, dado que a acusada é

primária (fls. 692693) – nunca tendo, nem ao menos, respondido por outro processo penal –, não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, o que autoriza a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'.

É que, conforme ficou demonstrado ao longo da instrução, a acusada Franciele realizou o delito de maneira esporádica, após convite para cometido do crime realizado pelo réu Wesley. Nesse sentido, inexistem elementos processuais que autorizem, de maneira segura, a pressuposição de que a acusada se dedique a atividade criminosa.

Note-se: a norma do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 tem justamente o intuito de distinguir entre aqueles que praticam o delito de tráfico de drogas de maneira esporádica e aqueles que fazem do ilícito seu 'modo de vida'. Isto é, não se exige, propriamente, que a prisão do acusado tenha ocorrido no único episódio de traficância de sua vida – o que, em tese, é o caso dos autos –, porém faz-se imprescindível demonstrar que o acusado 'se dedique' ao tráfico de drogas. Diante deste contexto, nota-se que não existem indícios suficientes de que a acusada integre organização criminosa ou se dedique de maneira 'profissional', permanente e reiterada ao tráfico – situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, mas, certamente, implica em diferenças, em relação aqueles que fazem do comércio ilegal de entorpecentes seu 'meio de vida'.

Ainda no ponto, destaco que, embora a quantidade de droga apreendida seja relevante – sobretudo considerando sua natureza e os padrões desta comarca de população reduzida (mais de 49g de cocaína) –, inexistente a comprovação dos elementos que impedem a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. É que, nos termos da jurisprudência já pacificada pelos tribunais superiores, a quantidade de drogas, por se, não é circunstância que de forma automática impeça a aplicabilidade da minorante, dado que a previsão da norma tem em vista o fato do réu estar ou não envolvido com organização criminosa ou se dedicar a atividade delituosa. No caso, nenhuma dessas circunstâncias restou caracterizada.

Por estas razões, em relação a acusada Franciele, entendo que preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

6.2. A norma penal prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, expõe como típica a conduta de “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

Conquanto o texto normativo determine como típica a conduta, independente de reiteração, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que a 'estabilidade e permanência' são imprescindíveis. Por todos, veja-se:

“1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes.” (RHC 108.003/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

No ponto, a jurisprudência – de maneira acertada – destaca, ainda, que os requisitos de 'estabilidade e permanência', exigidos para a configuração do delito do art. 35, da Lei 11.343/06, são distintos do elemento de reiteração – este sim dispensado.

“1.5. A estabilidade e permanência, que são elementares do crime de associação para o tráfico, não se confundem com a habitualidade ou reiteração criminosa. 1.6. Inexiste bis in idem em razão do não reconhecimento do crime continuado, pela habitualidade criminosa, e ainda, a condenação pelo delito de associação para o tráfico.” (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse sentido, o que se verifica é que para a configuração do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, faz-se necessário demonstrar que a associação para o tráfico preenche os requisitos de 'estabilidade e permanência' – requisitos que, note-se, também são exigidos para a configuração do crime do art. 288, do CP

(associação criminosa) -, prescindindo, no entanto, da comprovação de reiteração. Em outras palavras: a conduta do art. 35, da Lei 11.343/06, é típica, ainda que cometida uma única vez (ausência de reiteração), desde que demonstrada a 'estabilidade e permanência'.

No ponto, destaque-se que a exigência de estabilidade e permanência não ofende ao princípio da legalidade. Ao contrário, somente afirma uma diferença normativa e ontológica entre os art. 29, do CP (concurso de pessoas) e o tipo do art. 35, da Lei 11.343/06 (ou, para tais fins, também do art. 288, do CP). Afinal, há uma distinção essencial - reconhecida pelo legislador, sendo, portanto, também normativa - entre o cometimento de um delito juntamente com outro agente (art. 29, do CP - concurso de pessoas) e a associação para o cometimento de delitos (art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 288, do CP). Esta distinção é, justamente, a 'estabilidade e permanência'.

In casu, não restou demonstrado que os acusados tenham se associado, com estabilidade e permanência, para praticar as condutas previstas no art. 35, da Lei de Drogas. Ao longo da instrução não se apresentou qualquer prova nesse sentido. Não por outra razão, o i. representante do Parquet não postulou pela condenação no ponto. E razão, efetivamente, lhe assiste.

8. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que os réus são imputáveis, têm a consciência da ilicitude de suas ações, lhes era exigível conduta diversa e não agiam amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

Ante o exposto, restou claramente demonstrado que os acusados WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA e FRANCIELE FREITAS GODOI realizaram condutas típicas e antijurídicas, subsumíveis aos tipos penais indicados no art. 33, da Lei 11.343/06 - com aplicabilidade da causa de privilégio, no caso de Franciele, conforme acima exposto.

9. Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa. O delito do art. 35, da Lei 11.343/06, comina pena em abstrato de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

9.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social, o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A acusada Franciele é primária (fls. 692-693). O acusado Wesley (fls. 696-702) apresenta diversas condenações penais com trânsito em julgado. Assim, considerando o sistema escalonado de dosimetria, na forma do art. 68, do CP, a condenação dos autos 0002554-07.2015.8.26.0187 (art. 157, § 2º, I e II, do CP) será considerada para fins de reincidência e as demais nesta fase da dosimetria.

Ainda no contexto da primeira fase, o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, ambos os vetores pesam em desfavor dos acusados. Nos termos acima exposto, a quantidade de drogas apreendidas (49,2g de cocaína) é bastante significativa, sobretudo considerando a população desta cidade/comarca. Isto é, a quantidade é já, per se, suficiente à majoração. Ainda assim, é necessário ter em vista o contexto em que a conduta está inserida (cidade de pequeno porte), o que impõe, de maneira ainda mais criteriosa a necessidade de valorização do vetor previsto no art. 42, da Lei de Drogas. Igualmente, a natureza da droga deve ser analisada negativamente, uma vez que a substância em análise (cocaína) é capaz de gerar gravíssimos danos à saúde e implicar em forte dependência química, conforme consenso na comunidade científica. Desta maneira, conforme o exposto acima, fixo as penas bases em: (i) à acusada Franciele: (i) 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa; e (ii) ao acusado Wesley: 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

9.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes. No caso, o acusado Wesley é reincidente, conforme acima exposto, e inexistente atenuante em seu favor. A acusada Franciele não apresenta nenhuma agravante que pese contra si e faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na forma do art. 61, III, d, do CP. Considerando como fração aplicável à fase em análise o patamar de 1/6 (um sexto).

Desta maneira, conforme o exposto acima, fixo as penas intermediárias em: (i) à acusada Franciele: (i) 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e (ii) ao acusado Wesley: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

9.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição. In casu, presente a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em relação a acusada Franciele. É que, conforme exposto acima, a acusada é primária e ficou suficientemente demonstrado que não se decida à atividades ilícitas ou nem integre organização criminosa. No ponto, entendo que a benesse deve ser considerada em seu patamar médio (1/2), sopesando as circunstâncias do caso concreto (envolvimento de outras pessoas, transporte para outro município, intento de comercialização em local de concentração popular etc).

Pelo exposto, as penas definitivas ficam em: (i) à acusada Franciele: (i) 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa; e (ii) ao acusado Wesley: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

10. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e os antecedentes penais dos acusados, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo: ao acusado Wesley regime FECHADO para o início de cumprimento de pena; e à acusada Franciele regime inicial ABERTO para o início de cumprimento de pena.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração.

11. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

12. Em relação a acusada Franciele, a despeito da redação do art. 44, da Lei de Drogas, adotando entendimento consolidado nos tribunais superiores, entendo possível a substituição de pena no caso em análise, em razão do quantum de pena aplicado e o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor do acusado; e (ii) no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP.

Em razão da substituição, inviável a aplicação do art. 77, do CP.

13. Em relação ao acusado Wesley, incabível a aplicação dos art. 44 e art. 77, ambos do CP, em razão da quantidade de pena e da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

(i) com fundamento no art. 386, III, do CPP, ABSOLVER os acusados WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA, CAIO AUGUSTO GARCIA, MICHAEL WILLYAM CAMARGO VIEIRA e FRANCIELE FREITAS GODOI, já qualificados, pela suposta prática do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06;

(ii) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVER os acusados CAIO AUGUSTO GARCIA e MICHAEL WILLYAM CAMARGO VIEIRA, já qualificados, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06;

(iii) com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENAR o acusado WESLEY RIBEIRO ALVES DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, com juros e correção pela tabela do TJ-SP, a contar da data dos fatos;

(iv) com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENAR a acusada FRANCIELE FREITAS GODOI pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, com juros e correção pela tabela do TJ-SP, a contar da data dos fatos. Entretanto, nos termos do art. 44 do CP, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, por duas restritivas de direito, consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor da ré; e (ii) no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP. Permanece aplicável a pena pecuniária em dias-multa, uma vez que, nos termos do art. 44, do CP, apenas a pena privativa de liberdade é passível de substituição.

Custas pelos acusados Franciele e Wesley, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade que lhes sejam deferidas. Tendo em vista que a sentença penal não tem por consequência alterar de maneira automática e imediata a condição processual dos acusados, deixo de proceder com alterações a respeito das medidas cautelares em relação aos acusados Franciele e Wesley, revalidando-as, em razão inexistência de alteração do status fáticas ou jurídicas.

Em relação aos acusados Michael e Caio, considerando a absolvição acima decreta, revogo eventuais cautelares que pesem sobre os acusados, haja vista que inexistem os fundamentos do art. 282, do CPP.

Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

A respeito do dinheiro apreendido. Nos termos do art. 61, da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos valores apreendidos com Franciele, em favor da União. Em relação ao dinheiro apreendido com Caio, haja vista sua absolvição, devida a devolução do montante, dado que não caracterizada sua proveniência ilícita.

Em relação aos advogados que atuaram por força do convênio OAB/Defensoria, fixo honorários no valor de 100% (cem por cento) da tabela. Expeça-se certidão.

Serve a presente decisão como ofício/mandado/intimação.

Expeçam-se as guias e certidões necessárias.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado:

i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

iv. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

v. Expeça-se guia de execução penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

P.I.C.

Fatura, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA